

1500832-84.2020.8.26.0542

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Ana Paula Mezher Mattar

Comarca: Osasco

Foro: Foro de Osasco

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 28/06/2022

... está sendo aqui condenado pela prática de crime de tráfico de drogas, delito equiparado ao hediondo e isto porque - segundo a correta exegese - os delitos de natureza diferenciada, devem receber tratamento diferenciado.

Ninguém discute que o tráfico de drogas - de qualquer dimensão - constitui crime de exagerada periculosidade social, além da trágica e destruidora ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Osasco

Foro de Osasco

2ª Vara Criminal

Avenida das Flores, 703, Osasco - SP - cep 06110-100

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500832-84.2020.8.26.0542 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500832-84.2020.8.26.0542

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

NADINAEEL RODRIGUES SOARES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Ana Paula Achoa Mezher

Vistos.

NADINAEEL RODRIGUES SOARES e Pedro da Cunha Saraiva (autos desmembrados - fls. 178), qualificados nos autos, foram denunciados por infração ao artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque, segundo a denúncia, no dia 11 de abril de 2020, às 16h50, na Bento Teixeira, 1 - Portal D'Oeste, nesta cidade e comarca de Osasco, agindo em concurso, previamente conluiados e com unidade de desígnios, traziam consigo e guardavam, para fins de comercialização ilícita, drogas consistentes em 168 (cento e sessenta e oito) porções contendo 464,3g de Cannabis Sativa L (maconha); 73 (setenta e três) porções contendo 28,22g de cocaína e 63 (sessenta e três) porções contendo 13,25g de cocaína na forma de "crack", conforme auto de exibição e apreensão a fls. 08, laudo de constatação de fls. 24/31 e laudo de exame químico-toxicológico a ser juntado aos autos.

O réu foi notificado (fls. 163) e apresentou defesa preliminar (fls. 166/170).

A denúncia foi recebida em 17 de julho de 2020 e os autos foram desmembrados em relação ao correu PEDRO, face sua não localização (fls. 177/178).

Durante a instrução foram ouvidas duas testemunhas (fls. 209), sendo decretada a revelia do réu (fls. 215).

Em memoriais, o Ministério Público requereu a procedência da ação com a condenação do réu nos exatos termos da denúncia, e a decretação do perdimento dos valores apreendidos, por se tratar de produto do comércio ilícito de drogas (fls. 210/211).

A Defensoria Pública, por sua vez, arguiu preliminarmente, ilegalidade da prisão por guardas municipais, requerendo o desentranhamento dos autos de todas as provas, elementos e documentos decorrentes da prisão e apreensão realizadas em sede de flagrante, bem como requereu a absolvição do acusado por insuficiência probatória, com fulcro no artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, formulou pedidos relativos à dosimetria da pena, reconhecimento do redutor do §4º do art. 33 da LD, fixação de regime aberto, substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e a não condenação em custas (fls. 210/211).

Este é o relatório.
FUNDAMENTO e DECIDO.

Cumprе ressaltar, preliminarmente, no tocante às alegações de que os guardas civis municipais não têm competência legal para proceder abordagem de indivíduos na via pública, realizar revista pessoal e efetuar diligências, cumprе ressaltar inicialmente, que ao examinar a legalidade de prisão em flagrante efetuada por guardas municipais, o STJ fixou o entendimento de que não há objeção a essa ação, visto que, conforme o disposto no artigo 301 do Código de Processo Penal, “qualquer do povo poderá e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito”.

Entretanto, o entendimento jurisprudencial pacífico é contra a Defesa, isto é, entende-se que não há ilegalidade na prisão em flagrante efetuada por guardas municipais. O fundamento da legalidade desse ato decorre do já citado art. 301 do Código de Processo Penal, o qual permite que qualquer pessoa – particular ou servidor público – prenda quem estiver em flagrante delito.

Nesse sentido, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça:

“HABEAS CORPUS. IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ALEGADA INCOMPETÊNCIA DOS GUARDAS MUNICIPAIS PARA EFETUAR PRISÃO EM FLAGRANTE. PERMISSIVO DO ART. 301 DO CPP. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE TER SIDO VÍTIMA DE TORTURA. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO TRIBUNAL A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. RISCO DE REITERAÇÃO. QUANTIDADE E QUALIDADE DA DROGA. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. [...]. 2. Nos termos do artigo 301 do Código de Processo Penal, qualquer pessoa pode prender quem esteja em flagrante delito, de modo que inexistе óbice à realização do referido procedimento por guardas municipais, não havendo, portanto, que se falar em prova ilícita no caso em tela. Precedentes. [...] 6. Habeas corpus não conhecido. (HC 421.954/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/03/2018, DJe 02/04/2018).”

Da mesma forma, a Sexta Turma do STJ:

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. INADMISSIBILIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. GUARDA MUNICIPAL. NULIDADE DA SENTENÇA E DO ACÓRDÃO. NÃO OCORRÊNCIA. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. PROVA ILÍCITA. INEXISTÊNCIA. CRIME PERMANENTE. PARECER ACOLHIDO. [...] 2. Na hipótese dos autos, não há falar em nulidade da sentença e do acórdão sob a alegação de irregularidade na prisão em flagrante, visto que os integrantes da Guarda Municipal flagraram o paciente, em via pública, na posse de entorpecentes destinados à mercancia, estando suas condutas amparadas pelo art. 301

do Código de Processo Penal, segundo o qual qualquer do povo poderá e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito. 3. Apesar das atribuições previstas no art. 144, §8º, da Constituição Federal, se qualquer pessoa do povo pode prender quem quer que esteja em situação de flagrância, não se pode proibir o guarda municipal de efetuar tal prisão. 4. Em razão do caráter permanente do tráfico de drogas, cuja consumação se prolonga no tempo, a revista pessoal ou domiciliar que ocasionou a prisão em flagrante, não representa prova ilícita (Precedente). 5. Habeas corpus não conhecido. (HC 286.546/SP, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 22/09/2015, DJe 15/10/2015)."

Observe-se que as decisões não mencionam que o guarda municipal tem o dever de efetuar a prisão em flagrante, porque o art. 144, §8º da Constituição Federal, aponta nitidamente suas atribuições: "os Municípios poderão constituir guardas municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei".

No entanto, o que as supracitadas decisões afirmam é que não há uma proibição de que os guardas municipais prendam alguém em flagrante, haja vista que qualquer pessoa do povo também pode fazê-lo.

Dessa forma, inquestionável a legalidade da prisão em flagrante do réu, não havendo falar-se em ilicitude da prova acostado aos autos, conforme postulação da Defesa do acusado NADINAEI.

Quanto ao mérito, a ação penal deve ser julgada procedente.

Restaram demonstradas nos autos a materialidade e a autoria do crime de tráfico de entorpecentes com relação aos acusados na modalidade descrita na denúncia.

A materialidade do delito em tela está consubstanciada no boletim de ocorrência (fls. 02/05), auto de exibição e apreensão (fls. 08), laudo de constatação (fls. 24/31), laudo de exame químico-toxicológico, que apontou resultado positivo para TETRA-HIDROCANABINOL (THC) e COCAÍNA (fls. 205/207), bem como pela prova oral colhida.

Quanto à autoria, os elementos colacionados aos autos não deixam dúvida.

Em juízo, foi decretada a revelia do réu, pois, devidamente intimado, não foi localizado no endereço informado nos autos (fls. 215).

Na Delegacia, o acusado confessou os fatos, declarando que há cerca de um mês começou a vender drogas no local, pois está desempregado e que Pedro estava no local para avisar da chegada da polícia (fls. 10).

A confissão do acusado na Delegacia vem corroborada pela prova oral produzida em juízo e na fase inquisitorial. Vejamos:

A testemunha Gregory Alves da Silva, guarda municipal, declarou que estavam em patrulhamento pelo setor, quando avistaram dois indivíduos correrem ao perceberem a presença da viatura. Foram ao encalço dos indivíduos. Deteve NADINAEI e em seu poder encontrou, dentro de uma sacola, uma quantidade grande de porções de cocaína, maconha e crack, e determinada quantia em dinheiro. O outro rapaz foi detido por outra equipe. No momento da abordagem os dois confirmaram a prática do tráfico de drogas. NADINAEI vendia as drogas e o outro tinha a função de olheiro. Não os conhecia anteriormente. Recorda que a abordagem ocorreu no período da tarde. Disse, também, que no local da abordagem havia circulação de pessoas. Apenas o réu e o comparsa foram conduzidos para a Delegacia.

No mesmo sentido foi o depoimento do guarda municipal Advanio Santos de Miranda. Declarou que estavam em patrulhamento quando dois indivíduos avistaram a viatura e correram, o que motivou a perseguição e abordagem. Um dos indivíduos estava com uma sacola na mão. A sacola estava "recheada" com bastante cocaína, maconha e crack, além de dinheiro. Com o outro indivíduo nada de ilícito foi localizado. Um dos indivíduos falou que estava na campana e o outro indivíduo disse que estava no tráfico. Nunca tinha visto os réus anteriormente. Recorda que a abordagem ocorreu no período da tarde. Disse, também, que o local da abordagem é uma via pública movimentada com populares e moradias. Apenas os dois indivíduos foram conduzidos para a Delegacia.

Neste contexto, não há qualquer motivo para desmerecer os depoimentos dos guardas municipais que, como já consolidado pela doutrina e em nossa jurisprudência, tem o mesmo valor de qualquer outro testemunho, não só podendo mas devendo ser levado em consideração, eis que estes agentes públicos prestam compromisso legal de dizer a verdade e são possuidores de fé pública. Seria um contrassenso negar validade às suas afirmações, vez que investidos pelo Estado desta função repressora.

"São cansativas as alegações costumeiras contra a palavra dos policiais, como se eles sempre agissem fora da lei, em prejuízo de todos os acusados presos e autuados em flagrante. Mas, os depoimentos prestados por policiais não podem ser sumariamente desprezados apenas em razão de sua condição funcional, devendo ser aferida a sua credibilidade em função do exame atento do conjunto probatório existente nos autos. E na espécie em julgamento nada indica que os policiais ouvidos como testemunhas pudessem ter pretendido forjar essa grave acusação contra o apelante, a quem nem sequer conheciam". (Des. Antonio Luiz Pires Neto, RELATOR, Ap Nº 0002502-24.2008.8.26.0068).

Frise-se que não há razão concreta para se duvidar dos depoimentos dos policiais que no caso agiram no cumprimento de seu dever e sem nenhum sinal de abuso ou falso testemunho.

Os depoimentos dos agentes públicos foram unânicos ao confirmar as circunstâncias da abordagem do réu e do seu comparsa, bem como o encontro das drogas em seu poder, não havendo qualquer motivo concreto para afastar a veracidade de suas palavras. O guarda municipal Gregory deteve o réu NADINAEI e em poder dele encontrou, dentro de uma sacola, grande quantidade de porções de cocaína, maconha e crack, e determinada quantia em dinheiro.

Além disso, os relatos colhidos em juízo se coadunam com o quanto apurado em sede inquisitorial, inclusive a confissão do acusado na Delegacia (fls. 10).

Desta forma, o intuito de entrega a terceiros ficou caracterizado com a segurança possível nos autos, em especial diante das circunstâncias da abordagem, isto é, a presença de drogas embaladas individualmente, além de certa quantia em dinheiro, o que corrobora o intento de venda do acusado.

Assim, a coligação das provas contidas nos autos - da formação do inquérito policial ao momento de prolação da sentença - encontra-se apta a demonstrar a prática de comercialização de entorpecentes. Afasta-se, pois, qualquer possibilidade concernente à absolvição ou desclassificação.

Não há, pois, desta forma, como se falar em insuficiência probatória para os fins colimados pela defesa.

Passo a dosar a pena.

No que diz respeito à consideração das circunstâncias judiciais, tal qual previsão do art. 59 do Código Penal, em primeira fase de fixação da sanção, fixo as penas em

5 anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa.

Em segunda fase de estabelecimento de sanção nada se verifica a alterar a pena-base. As atenuantes relativas à confissão na Delegacia e à menoridade devem ser desprezadas, pois a pena-base foi fixada no mínimo legal.

Em terceira fase, entretanto, o réu não faz jus ao redutor previsto no §4º do art. 33 da Lei de Tóxicos. A grande quantidade de entorpecente, assim como a diversidade de drogas (mais de 300 porções de entorpecentes, distribuídos entre maconha e cocaína) indica o grande poder de comercialização do acusado, demonstrando, assim, uma maior periculosidade do agente. As circunstâncias da prisão dele as separam do traficante "pequeno", conferindo um verdadeiro caráter criminoso e de dedicação a atividades criminosas, não fazendo jus ao redutor.

Não havendo outros elementos que possam alterar a pena fixada, torno definitiva a reprimenda aplicada.

O regime inicial de pena, no caso, deve ser o FECHADO.

O acusado está sendo aqui condenado pela prática de crime de tráfico de drogas, delito equiparado ao hediondo e isto porque – segundo a correta exegese – os delitos de natureza diferenciada, devem receber tratamento diferenciado.

Ninguém discute que o tráfico de drogas – de qualquer dimensão – constitui crime de exagerada periculosidade social, além da trágica e destruidora repercussão social-familiar que traz inevitavelmente. Além disso, é sabido que a violência e grave ameaça à incolumidade pública são presumidas, de maneira que outro não poderia ser mesmo o tratamento dado pelo legislador (por meio da lei de crimes hediondos), até mesmo por uma interpretação e tratamento lógicos do sistema.

Pelos mesmos motivos e com estes mesmos fundamentos, inegável que não se aplica no caso, inobstante a Resolução 05 de 15 de fevereiro de 2012, do Senado Federal (Art 1º: É suspensa a execução da expressão 'vedada a conversão em penas restritivas de direitos' do § 4º do art. 33 da lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006, declarada inconstitucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal nos autos do Habeas Corpus nº 97.256/RS), a substituição da pena corporal por restritiva de direitos.

Inegável que as substituições previstas no artigo 44 e seguintes do Código Penal não funcionam como reprimendas penais, tal como deve ocorrer nos crimes de tráfico de drogas, de tal sorte que este tratamento do legislador (benevolente), não se destina aos delitos hediondos (onde tais medidas por certo não são socialmente recomendáveis).

Inegável também que fixar-se o regime fechado para início do cumprimento da pena e depois substituir o cárcere por uma pena alternativa, revelaria inexplicável contradição, que certamente não se coaduna com a Constituição Federal (que pontua o princípio da igualdade, da individualização da pena, pois outros condenados por crimes diversos não podem se ver com as mesmas reprimendas e regime de pena que os condenados por tráfico); com a legislação infraconstitucional (que equiparou o tráfico aos crimes hediondos) e ainda aos tratados internacionais dos quais o Brasil é signatário (que buscam também a repressão deste nefasto crime).

A isso, some-se que a substituição da pena privativa de liberdade por sanção restritiva de direitos é instrumento destinado a evitar a retirada do convívio social de condenados por delitos de menor potencial ofensivo, situação bem diversa da hipótese vertente, que trata de crime classificado como hediondo, cuja prática revela toda a temibilidade do agente, a impor resguardo da sociedade com o efetivo desconto da sanção carcerária, revelando, assim, ser a substituição de todo

incompatível com os propósitos traçados pela legislação especial.

Ante ao exposto e por tudo o que dos autos consta JULGO PROCEDENTE a presente ação penal para condenar NADINAEL RODRIGUES SOARES, qualificado nos autos, como incurso no artigo 33, caput da Lei nº 11.343/2006, ao cumprimento da pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 500 dias-multa, esses no mínimo legal, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Autorizo a incineração da droga apreendida com o acusado, acaso ainda não incinerada.

O réu NADINAEL foi solto no curso do processo e não obstaculizou seu trâmite processual. Portanto, DEFIRO a possibilidade de recurso em liberdade.

Após o trânsito em julgado desta, lance-se o nome do réu NADINAEL no rol dos culpados.

Custas na forma da Lei.

P.R.I.C.

Osasco, 28 de junho de 2022.

Ana Paula Achôa Mezher
Juíza de Direito
(assinado digitalmente)

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA